

1500797-73.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500797-73.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500797-73.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELIAS CARDOSO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

ELIAS CARDOSO DE SOUZA e JEFFERSON MICHEL RIBEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, e no art. 33, § 1º, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 29, caput, e na forma do caput do art. 69, ambos do Cód. Penal.

Consta que no dia 06 de junho de 2020, por volta das 17h, na Rua Felipe Abraão Maluf, 201, nesta cidade e comarca, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, os réus, para futura entrega a terceiros, doze porções de "crack", pesando 569,14g e dezessete porções de "maconha", pesando 131,46g, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os réus, duas balanças, um rolo de plástico filme e R\$ 190,00.

Na mesma ocasião, teriam os réus utilizado imóvel, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Policiais militares, com informações sobre a prática do comércio ilícito, abordaram os réus na via, defronte às respectivas residências.

Com Jefferson, encontraram os agentes, nas vestes, duas porções de "maconha", bem como, no interior do imóvel, outras duas porções da mesma droga e uma balança.

O acusado Elias tentou fugir para o interior da residência ao perceber a aproximação da viatura, dispensando, durante o trajeto, doze porções de "crack". Abordado, localizaram os agentes, com Elias o dinheiro, além de, no imóvel, treze porções de "maconha", uma balança e um rolo de plástico filme. Oferecida a denúncia foi o réu Elias notificado e apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e uma apontada pela defesa. Após, foi interrogado o réu Elias.

Destaco estarem em foco apenas os delitos imputados ao réu Elias.

Com relação a Jefferson, foi o feito desmembrado ante a não localização e a citação por edital.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação do acusado Elias.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu Elias sustentando, em suma, insuficiência de provas a delinear o crime.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso no imóvel decorreu, por primeiro, ante ao estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes durante abordagem inicial, e, ao depois, ante autorização do réu e de familiares, que, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância do denunciado, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei nº 11.343/06). 2. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garante ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n. 306.560/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 3. Uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Para rever a conclusão da instância de origem, quanto à ausência de autorização para a entrada no domicílio, seria indispensável a revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço em recurso especial, em razão da vedação da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, REsp 1.909.082-AgRg/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 02.02.2021).

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, que revela o encontro dos entorpecentes, das balanças, do rolo de plástico filme e do dinheiro em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 21/23 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 110/112, concludentes no sentido de se tratar de

Tetrahydrocannabinol – THC e de cocaína, as substâncias encontradas.

Os petrechos foram vistoriados, constatando-se resquícios de “maconha” e de cocaína nas balanças (fls. 106/108).

Em ambas as manifestações, admitiu o réu Elias a execução do comércio ilícito, contudo, negou comparsaria com Jefferson.

Em Juízo, assegurou Elias ser possuidor apenas da “maconha”, que usava e negociava, sem auxílio do corréu.

Contam os policiais terem, após informações de populares sobre a execução da traficância, abordado os réus na via pública, defronte às respectivas residências, ocasião na qual encontraram, nas vestes de Jefferson, porções de “maconha”, bem como, no interior do imóvel deste, outras duas porções de tóxico e uma balança. Explicaram ter Elias tentado fugir para o interior da residência, ao notar a viatura, dispensando, durante o trajeto, doze porções de “crack”. Continuaram os agentes no sentido de terem, em revista pessoal a Elias, localizado o dinheiro e, no imóvel, o restante das drogas e dos petrechos.

Rodrigo Sandoval, escrivão de polícia, acompanhou, em solo policial, a oitiva de Elias, que admitiu a prática da traficância.

Vale lembrar que o fato de agentes que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais militares incriminar o réu Elias ou forjar o crime. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

A esposa de Elias assegurou não existir droga na residência, mas sim em terreno vizinho, onde havia criação de animais. Disse que o réu guardava “maconha” neste terreno vizinho, mas para uso.

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu Elias, que não comprovou relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a guarda, transporte e negociação do produto, medida impositiva.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.

11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso" (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

O que importa, no caso, é ter sido o entorpecente localizado com o réu Elias, em situação de comercialização, o que acontecia com envolvimento de Jefferson.

A quantidade da droga apreendida e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por Elias mantida em depósito e posta em comércio, até porque, não conta com situação financeira que o permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

Além disso, a condição de usuário não afasta a de traficante.

Urge destacar não ter a defesa apontado, de forma cristalina, terem policiais apresentado tóxico não achado na posse do réu Elias, e nem motivo haveria para tanto, até porque, trata-se de pessoa desconhecida dos agentes. Por isso, tal versão é indigna de crédito.

Ainda, eventual dificuldade financeira, apontada pelo réu, não autorizaria, de forma alguma, a prática criminosa. Até porque, se assim não fosse, desnecessária seria a existência de normas legais, reguladoras do comportamento humano.

Em relação ao crime tipificado no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06, descabida a condenação do acusado Elias, pois certo é ter o réu guardado e mantido em depósito, na residência, o entorpecente e os petrechos destinados à traficância, subsumindo-se tais condutas ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da especificada Lei.

As condutas atinentes aos dois tipos penais foram cometidas no mesmo contexto fático, aplicando-se, portanto, o princípio da consunção para que o agente seja punido apenas pela finalidade última, ou seja, o tráfico de drogas.

Portanto, AFASTA-SE, em razão da consunção, a acusação de utilização de imóvel, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Nesse sentido a edição 126 de "Jurisprudência em Teses", do Superior Tribunal de Justiça: "É possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou no art. 34 pelo tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta".

Convencida da responsabilidade penal do réu Elias, passo a individualizar as penas.

- ELIAS CARDOSO DE SOUZA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da elevada quantidade, da variedade e da natureza da substância apreendida.

Verificada a confissão da autoria, incide a circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, razão pela qual reduzo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena do réu Elias, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a

prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da lei em tela, ante a quantidade e variedade de entorpecentes, bem como o concurso de agentes, fatos a apontar maior periculosidade do réu, indicando dedicar-se à atividades criminosas, mesmo porque, não existe comprovação de atividade laborativa.

Nesse sentido a doutrina: "de mais a mais, tem-se decidido que apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena." (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius, Lei de Drogas: aspectos penais processuais. 2021, p. 107).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno ELIAS CARDOSO DE SOUZA, R.G. n.º 31.781.900, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 29, caput, do Cód. Penal.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores

do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública. Recomende-se o réu Elias no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO dos petrechos, porque utilizados como instrumentos do crime, bem como do dinheiro (fls. 12/13), pois obtido em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA